

1500686-61.2022.8.26.0481

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Sim, Negeba é conhecido nos meios policiais por tráfico e, inclusive, hoje ele foi preso por tráfico. Existem informações de várias pessoas que traficam naquele local. E o mesmo local de atuação: tem o Cléber, o Negueba, o Éder...Ele nos informou, salvo engano, que teria passado um tempo no Paraná. Não, não, estava só ele. Isso, perfeitamente. Não, para os usuários usarem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500686-61.2022.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500686-61.2022.8.26.0481 - Feito nº 2022/001994

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER JOSÉ FERREIRA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2212165/2022, ofereceu denúncia em face de CLEBER JOSÉ FERREIRA DIAS, devidamente qualificado às fls. 32, dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 04/08/2022, por volta das 16h30, na Rua Miguel Pedro Miguel, 2654, nessa cidade e Comarca, CLEBER JOSÉ FERREIRA DIAS estaria trazendo consigo e guardando, para entrega a consumo de terceiros, 25 porções de crack, pesando 03 gramas, droga capaz de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar.

Realizada audiência de custódia virtual, nos termos do Provimento CSM nº 2.629/2021, após a entrevista do autuado e manifestação do ilustre representante do Ministério Público e da nobre Defesa, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva na data de 05/08/2022 (fls. 49-56).

Notificado (fls. 93), o acusado ofertou defesa prévia, momento em que requereu a revogação da prisão preventiva e pugnou pela realização de exame datiloscópico na droga apreendida (fls. 100-114).

Laudo de exame químico de entorpecente acostado (fls. 123-125).

A denúncia foi recebida em 29/09/2022, ocasião em que foi rejeitada a hipótese de absolvição sumária, indeferido o pedido de realização de exame datiloscópico,

mantida a prisão preventiva do acusado e, com fundamento no artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, que autorizou a realização das audiências por videoconferência ou mistas em todas as matérias, designada audiência de instrução, debates e julgamento de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams (fls. 126-130).

O réu foi regularmente citado (fls. 150).

Prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado (fls. 164-171).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de CLEBER JOSÉ FERREIRA DIAS pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 03-05), auto de exibição e apreensão (fls. 18-19), auto de constatação da natureza tóxica (fls. 14) e laudo pericial químico de entorpecente (fls. 123-125), que atestou que a substância detectada se tratava de Tetrahydrocannabinol (THC), que é de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado CLEBER JOSÉ FERREIRA DIAS.

Inquirida, a testemunha NEUMIR CESAR DA CUNHA CARMIONATTI, policial militar, relatou que "Sim, senhora. Na data dos fatos, em policiamento pela Vila Esperança, em Presidente Epitácio, na rua mencionada avistamos um indivíduo que, ao ver a viatura, correu para uma residência abandonada. Eu e o cabo Leite o seguimos e, no corredor do lado de fora, vimos o rapaz tentar jogar algo na caixa de gordura, enquanto tentava pular o muro. Feita a abordagem, encontramos com o rapaz R\$ 50,00. Fui checar o que havia na caixa de gordura, quando me deparei com 25 porções de crack. Sim, senhor. Sim. Não, senhora, avistamos o Cléber, que, ao avistar a viatura, entrou para dentro da residência, jogou o invólucro na caixa de gordura e, posteriormente, tentou pular o muro pela lateral, sendo, na sequência, abordado. Sim, senhora. Sim, de concreto. Não, ela estava descoberta e seca. Não sei se, por coincidência ou não, prendemos Nogueira hoje por tráfico de drogas. Sim, senhora. Ele nos relatou que estava ali para fumar um baseado de maconha, mas não foram localizados nem maconha, nem seda, nem isqueiro. Ele não soube precisar a procedência do dinheiro".

No mesmo sentido, o também policial militar GUSTAVO CESAR LEITE complementou "Nós estávamos em patrulhamento pela via, naquele local, quando o avistamos. Ao nos perceber, ele entrou correndo em uma casa desabitada, jogou um objeto em uma caixa de gordura e tentou fugir da abordagem, pulando o muro. Porém, ele foi abordado por mim e trazia consigo R\$ 50,00. O sargento Neumir identificou as porções de crack na caixa de gordura. Ele dizia que era usuário de maconha, mas não achamos com ele papel de seda, isqueiro ou qualquer outro petrecho típico de usuário e ele não soube identificar o que havia ali. Sim, porque o Sargento ficou do lado de fora, eu já fui entrando e consegui contê-lo no muro, enquanto o Sargento conseguiu identificar quando ele jogava o objeto na caixa de gordura. Sim, Negeba é conhecido nos meios policiais por tráfico e, inclusive, hoje ele foi preso por tráfico. Existem informações de várias pessoas que traficam naquele local. E o mesmo local de atuação: tem o Cléber, o Nogueira, o Éder...Ele nos informou, salvo engano, que teria passado um tempo no Paraná. Não, não, estava só ele. Isso, perfeitamente. Não, para os usuários usarem não".

Interrogado, o acusado CLEBER JOSÉ FERREIRA DIAS negou a prática delitiva, dizendo que "Eu queria falar sim, Vossa Excelência. Eu não estava. Quando eu avistei a

viatura, porque estavam me perseguindo fazia uma semana, fiquei com medo deles me baterem, porque sou cheio de tatuagem e corri realmente. Mas o dinheiro que eu trazia era destinado à minha filha. Porque eu tenho passagem e, sempre que eles me encontram na rua, me agridem, me perguntam de traficante e não sei nada disso. Porque na rua, eles já me pegaram, me levaram para outro lugar e me bateram. Não fiz denúncia, porque seria minha palavra contra a deles, que tem maior valor. Não, porque eles me bateram em lugares em que não ficam marcas, no rosto, deram um tapa na minha cara. Eu trabalhava, morava no Paraná, não estava com registro, porque minha CTPS estava aqui, mas meu patrão tinha me dado uns dias para voltar a Epitácio, pegar minha CTPS e voltar ao Paraná. O dono da droga é o Negeba, conhecido como Fabrício. Ninguém perguntou, porque não chegou a andar com ele, não ando com maloqueiro para não ser julgado com maloqueiro. Mora gente naquela casa sim, sei, porque já passei lá por várias vezes e vi uma pessoa lá. Isso, por isso que eu pedi a digital: como a droga é minha se não tem a minha digital? Deus sabe que não coloquei, tinha muita certeza que não sairiam minhas digitais, por isso que pedi o exame das digitais sobre as drogas. Porque eles me falaram que a droga era do Negeba, eles já chegaram falando que a casa tinha caído, que eles queriam um traficante, que o Negeba teria me caguetado..."

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado se encontra em dissonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas policiais militares que empreenderam as investigações e efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livra-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrerealidade.

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado.

As testemunhas de acusação descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos, de forma que, tratando-se de versão escusatória, cabia ao réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito nestes autos.

Seria, inclusive, assimilar um enredo quicá fantasioso concluir que, depois de correr para uma casa abandonada após avistar uma viatura policial, policiais militares, apenas por implicância em razão de seu histórico criminal desabonador, plantaram considerável quantidade de entorpecentes.

A presunção iuris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir

que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Nessa toada:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal . O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a relevante quantidade de entorpecente e o modo de acondicionamento (25 invólucros plásticos, embalados individualmente e prontos para o comércio, pesando 03 gramas - fls. 18, 21-23 e 123-125); a tentativa de ocultação do entorpecente (o acusado, ao visualizar a viatura policial, adentrou no quintal de uma casa abandonada e dispensou a droga em uma caixa de gordura localizada no corredor lateral da casa); a questionável a origem financeira dos valores apreendidos (R\$ 50,00), eis que nenhuma prova idônea foi trazida aos autos para comprovar sua licitude; e o anterior envolvimento do acusado com a traficância (fls. 34-43) revelam que se tratava sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque o acusado ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado. Assim, utilizo uma para fins de maus antecedentes (autos 1500691-88.2019.8.26.0481 - fls. 34-43) e uma para fins de reincidência (autos 1500502-13.2019.8.26.0481), a ser avaliada no momento oportuno. Outrossim, o comércio de substância altamente letal ao ser humano, qual seja, crack também impõe uma elevação ao piso legal. Nesse passo, aumento a pena base no montante de 1/5, resultando-se em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, vislumbro presente a circunstância agravante da reincidência específica (autos 1500502-13.2019.8.26.0481- fls. 34-43), impondo-se um agravamento de 1/6 às penas anteriormente fixadas, resultando-se em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Na terceira fase de cálculo penal, considero inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que o legislador do texto da referida norma quis favorecer o autor eventual de tráfico de "pequena" monta, para hipóteses extremamente excepcionais e especiais, em que todas as

circunstâncias sejam absolutamente favoráveis ao autor do delito, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o acusado é reincidente, requisito objetivo que impede a aplicação da minorante. Assim, torno definitivas as penas de 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, à míngua de outros elementos modificadores. Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da multirreincidência e do elevado efeito deletério, poder viciante da substância entorpecente crack apreendida, além de inquestionável lesividade à higidez física ou psíquica de usuários.

Nessa toada:

"(...) REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. (...) - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta é necessário fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. - No caso, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas são circunstâncias que recomendam o regime mais gravoso para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. - Habeas corpus não conhecido." (STJ. HC 344.946/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ademais, a fixação de regime inicial mais brando, por tratar-se de atividade altamente lucrativa, não alcançaria, de forma expressiva, uma vez que a sanção para tal delito deve ser proporcional ao benefício proporcionado a quem o pratica, os objetivos de repressão e prevenção visados pelo Direito Penal.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/12, por se tratar de hipótese de progressão de pena que, pelo nosso ordenamento jurídico, requer a análise cumulativa do requisito subjetivo, tais como informações sobre o comportamento carcerário do réu e existência de outros processos, o que não é possível neste momento processual. Ressalto, assim, que tais informações devem ser verificadas junto ao Juízo das Execuções Criminais, o qual é responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.

Nesse sentido:

"(...) A detração penal descrita no artigo 387, § 2º, do CPP, incluído pela Lei n.º 12.736/2012, refere-se à necessidade de computar o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação do sentenciado, para fins de fixação do regime inicial. 2. Entretanto, o magistrado não está obrigado a escolher o modo mais benéfico para início do desconto da reprimenda, podendo manter o mais gravoso ainda que quantum de pena resultante permita a fixação de regime mais brando. (...)." (STJ, HC 356.658/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016).

E, pelos mesmos motivos já explanados, nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR CLEBER JOSÉ FERREIRA DIAS, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Observando-se o artigo 387, § 1º, do CPP, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, eis que persistem os temores autorizativos da prisão cautelar, devendo o Estado precaucionar-se a fim de garantir a manutenção da ordem pública. A razão da custódia está alicerçada máxime porque, condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, o sentenciado é reincidente específico, demonstrando que as penas anteriormente concedidas, inclusive regimes mais benéficos, não foram suficientes à ressocialização, a indicar a absoluta necessidade de resguardo da ordem pública.

Assim, recomendo o réu na prisão em que se encontra, cabendo a comunicação por ofício, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão, nos termos do artigo 431, §1º, da NSCGJ.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Concedo ao sentenciado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita.

Considerando que foram apreendidos nos autos R\$ 50,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 19), nos moldes do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 63, § 1º, da lei 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento dos valores (depósito judicial às fls. 69) em favor da União e o seu encaminhamento ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em virtude dos fundamentos utilizados nesta sentença.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Autorizo a incineração da substância entorpecente remanescente, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

de Presidente Epitácio, 09 de novembro de 2022

MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MAGISTRADO(A), NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.